

1500142-02.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500142-02.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000098

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017370/2022 - 01º D.P.

DIADEMA, 2017370 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Dario da Silva Oliveira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

DARIO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 16/17, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 13h00, na Rua Almirante Cockrane, altura do nº 150, Conceição, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 20 embalagens plásticas contendo 10,1g da droga cocaína, 07 embalagens plásticas contendo 0,7g da droga cocaína, na forma de crack, e 25 embalagens plásticas contendo 50,0g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 10/11 e laudo de constatação provisória de fls. 13/14, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.39/42), o réu foi notificado e citado, e apresentou defesa preliminar, através do Defensor Público /Advogado constituído, pugnando pela liberdade provisória e absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates

orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, com considerações acerca da reprimenda, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado.

Já o d. Defensor Público pugnou pela fixação das penas em patamares mínimos; requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. , nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/05), estavam em operação rotineira de trabalho, deslocaram-se até o local dos fatos, conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Assim que lá chegaram, realizaram campana, visualizando o movimento de pessoas no ponto de venda de drogas. Foram capazes de observar algumas pessoas entregando quantia em dinheiro para um indivíduo, que retirava uma porção de droga de uma sacola plástica, de cor verde, que se encontrava escondida em um buraco no muro a cerca de 2 metros de distância de onde ele estava. Notaram que esse mesmo procedimento fora realizado pelo suspeito com a chegada de outros transeuntes. Sendo assim, rapidamente se aproximaram e obtiveram êxito em abordá-lo, sendo nada de ilícito encontrado em seu poder. Ao ser questionado, o suspeito, identificado como Dario da Silva Oliveira, confessou que estava no local traficando, mas não deu maiores detalhes sobre para quem trabalhava. Em seguida, foram até o referido muro, de onde tiraram, de dentro de um buraco, uma sacola plástica, que continha em seu interior: R\$22,00 em espécie; 7 pedras de crack; 25 invólucros contendo maconha; e 20 invólucros contendo cocaína.

Sob o crivo do contraditório o policial Elvis Leonardo referiu depoimento em sentido similar, confirmando a localização dos entorpecentes na posse do réu, após breve campana; houve confissão pelo réu no local.

Igualmente o policial Mauro Roberto trouxe versão similar, confirmando que se trata de local típico para a traficância de entorpecentes. Havia dinheiro também, proveniente da traficância.

O réu, em solo policial (fl.05) confessou a autoria do crime de tráfico de drogas. Que estava comercializando as substâncias apreendidas instantes antes de ser detido pelos policiais civis. Que recebe R\$ 30,00 por um período de doze horas, recebendo, ainda, 30%, à título de comissão, da quantia proveniente da venda das drogas. Que iniciou a prática delitiva, no dia de hoje, às 08:00h. Esclareceu que o dinheiro encontrado é fruto da mercancia das drogas.

Em juízo o acusado confessou os fatos em que fundada a pretensão punitiva; queria usar drogas, e para não roubar ninguém, topou envolver-se com a traficância de entorpecentes.

Logo, a confissão não é prova única, pois veio corroborada pelos testemunhos dos

policiais - que são válidos e eficazes para a condenação condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - até porque presenciaram os atos de traficâncias, ou seja, pessoas indo até o réu, ele se distanciando cerca de dois metros até o esconderijo das drogas, onde as buscava e entregava ao usuário, que ia embora em poder do narcótico. Tanto que a prova oral está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu, como visto, sempre confirmou estar traficando drogas no local, sendo seu primeiro dia, e que o valor apreendido consigo era proveniente dessas vendas ilegais.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ressalto que o argumento de que os acusados Bruno e Lucas praticaram o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu: 'Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). TJ/SC: Desemprego não é motivo para excludente de ilicitude de tráfico 17/08/2021 - Admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. O entendimento serviu de base para a 5ª câmara Criminal do TJ/SC negar apelação de um homem flagrado com meio quilo de cocaína em seu veículo, durante abordagem de policiais rodoviários. Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030

Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (72 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 10) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho as penas bases nos mínimos legais, consoante postulam Ministério Público e Defensoria Pública.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena em similar patamar.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu plurirreincidente, específico, a indicar que faz do crime seu meio de vida,

inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos: objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente é reincidente específico). Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em que pese a

Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência específica do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, até por ser o regime legal (Lei n. 11.454/07).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, além de já ter duas condenações definitivas por outros dois tráficos, em abril e em agosto de 2021. Ademais: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP,

rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra DARIO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 16/17, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de bens e valores apreendidos nos autos, com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA